

1501350-29.2022.8.26.0599
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira
Comarca: Piracicaba
Foro: Foro de Piracicaba
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 29/11/2022

... no processo.

Neste sentido:

APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Valor do depoimento testemunhal de servidores policiais que, ratificados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Inexistência de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19) 3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501350-29.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2244791/2022 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 27269099 -

DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2244791 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DURVAL ALEXANDRE ANTONIO DE ALMEIDA

Vítima:

DIEGO AUGUSTO DO VALE MORAES

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 28 dias do mês de novembro de 2022*, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se (o)a Exmo(a). Sr(a). Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MM. Juiz(a) de Direito, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). Paulo Kishi e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a). Marcelo Dayrell Vivas. Apresentados o acusado e as testemunhas arroladas em comum pelas partes: Francisco Dernival Miranda Júnior e Juvenal Estevão de Macedo.

Ausente a vítima Diogo Augusto do Vale Moraes, não intimado pelo Oficial de Justiça.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s)

com seu(sua)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao(a)(s) acusado(a)(s) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pelo(a) MM. Juíz(a) foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) (Francisco e Juvenal) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado(a)(s) o(a)(s) réu(ré)(s). Pelo Promotor de Justiça foi dito que desiste da oitiva da vítima Diego. Em seguida, pelo(a) MM Juíz(a) foi deliberado: Homologo a desistência das partes em relação à vítima Diego Augusto do Vale Moraes. "Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais: Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos: MM. Juíza,

DURVAL ALEXANDRE ANTONIO DE ALMEIDA, qualificado nos autos, está sendo regularmente processado como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal porque, no dia 07 de setembro de 2022, por volta de 09h10min., na rua da Palma, nº 2.790, bairro Paulista, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, agindo em concurso e com identidade de desígnios com pessoa não identificada nos autos, subtraiu, para si ou para outrem, um botijão de gás modelo doméstico, cor verde, um aparelho de som, uma lavadora de roupa, um notebook, um instrumento musical denominado loop station, um retroprojeter e um megafone pertencentes a Diego Augusto do Vale Moraes. A denúncia foi recebida a fls. 130/131. O réu foi citado (fls. 138) e a Defensoria Pública apresentou defesa prévia (fls. 143/147). Os fatos imputados na exordial acusatória foram comprovados ao longo da instrução criminal, pelo que a ação é procedente. A materialidade foi comprovada através do boletim de ocorrência (fls. 09/12), auto de exibição e apreensão (fls. 14) e Laudo Pericial do local (fls. 167/183). A autoria, da mesma forma, é indubitosa. Segundo se apurou, o denunciado e o comparsa não identificado arrombaram a janela, ingressaram na casa da vítima e subtraíram os objetos acima descritos. Na sequência, quando carregava na via pública o botijão de gás, o denunciado foi abordado e confessou a subtração na companhia de pessoa conhecida por "Lagoa", mas não apontou aonde estavam os demais objetos furtados. Com efeito, em solo policial, a vítima Diego Augusto do Vale Moraes declarou que reside no imóvel, mas que na data dos fatos estava na casa de sua genitora. Afirmou que "(...) foi informado por guardas municipais de que alguns objetos haviam sido furtados do interior da sua residência. Que, de imediato, se deslocou até o imóvel, onde constatou que o portão e uma janela haviam sido arrombados, e diversos objetos, subtraídos de seu interior, dentre os quais um aparelho de som, uma máquina de lavar, um botijão de gás, um projetor de imagens, um notebook, um pedal de voz, além de outros itens. Que, ainda no local, reconheceu como seu, sem qualquer dúvida, o botijão de gás localizado com o implicado. Que acredita que o furto ocorreu nesta madrugada, oportunidade em que não se encontrava no imóvel". A palavra da vítima foi confirmada pelos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo. Francisco Dernival Miranda Júnior, guarda municipal, confirmou o depoimento na fase policial, oportunidade em que disse que "(...) estava com seu parceiro de farda em patrulhamento de rotina pela rua da Palma, nesta urbe, quando se depararam com o indiciado, que trazia em suas costas um botijão de gás envolto por uma blusa de moletom, o que despertou suspeitas. Que, realizada abordagem com o suspeito nada de ilícito foi localizado. Que, indagado, confessou que, na companhia de um de tal de "Lagoa", havia subtraído o botijão e diversos outros itens do interior da residência situada na Rua Madre Cecília, 1453, tudo após prévio arrombamento. Que o averiguado não esclareceu quem era o tal "Lagoa" nem onde estavam as demais coisas furtadas. Que, de imediato, fizeram contato com a vítima, a qual confirmou o furto dos seus pertences, reconhecendo como seu, sem qualquer dúvida, o botijão localizado em poder do implicado. Que restou apurado, ainda, que o indiciado

ingressou na residência após arrombar uma das janelas do imóvel” (fls. 04). Em juízo ratificou integralmente o depoimento prestado na fase policial. Os demais bens subtraídos não foram recuperados. O réu confirmou que arrombou o local com o co-autor e ambos fizeram a subtração dos bens. Não conhecia o réu antes dos fatos. A vítima foi localizada e constatou os bens que haviam sido subtraídos. No mesmo sentido o depoimento do guarda municipal Juvenal Estevão de Macedo, que afirmou em solo policial que “(...)data e horário dos acontecimentos, estava com seu parceiro de farda, ora condutor, quando, ao realizar patrulhamento pela rua da Palma, nesta urbe, se depararam com o indiciado, a quem decidiram abordar. Que a fundada suspeita decorreu do fato dele estar trazendo consigo um botijão de gás envolto por uma blusa de moletom. Que, realizada a abordagem, com o suspeito, nada de ilícito foi localizado. Que, indagado, confessou que, na companhia de um de tal de “Lagoa”, havia subtraído o botijão e diversos outros itens do interior da residência situada na Rua Madre Cecília, 1453, tudo após prévio arrombamento. Que o averiguado não esclareceu quem era o tal “Lagoa” nem onde estavam as demais coisas furtadas. Que, de imediato, fizeram contato com a vítima, a qual confirmou o furto dos seus pertences, reconhecendo como seu, sem qualquer dúvida, o botijão localizado em poder do implicado. Que restou apurado, ainda, que o indiciado ingressou na residência após arrombar uma das janelas do imóvel” (fls. 05). Em juízo ratificou o depoimento prestado na fase policial. A vítima confirmou a subtração. Ela foi localizada através de documentos que estavam no local. Ela compareceu ao local e confirmou o rol de bens subtraídos. Em solo policial, o réu negou a prática do crime. Disse que “(...) apenas acompanhou o autor do furto, a quem conhece pela alcunha de 'Lagoa', mas sabe que se trata de um homem moreno, com cerca de 25 anos, que ostenta barbas e que vive na rua, nas cercanias da 'Paulista'. Que também desconhece o destino das demais coisas furtadas” (fls. 07/08). Em juízo, o réu alegou que é dependente químico e no dia dos fatos esteve no local e recebeu o botijão de gás do tal de Lagoa. Assim, restaram indúvidas autoria e materialidade delitivas. A vítima reconheceu prontamente como seu o botijão de gás que estava na posse do réu. Aos guardas municipais, o réu admitiu a subtração, indicou o endereço do imóvel furtado aos policiais e declarou que o crime foi praticado na companhia de um co-autor, apenas identificado pela alcunha de “Lagoa”, em relação a quem, inclusive, descreveu as características físicas. Pertinente salientar que não há nada que invalide os depoimentos dos guardas municipais, devendo ser valorados como as demais provas constantes no processo. Neste sentido: APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Valor do depoimento testemunhal de servidores policiais que, ratificados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Inexistência de contradições ou elementos de convicção que possam retirar-lhe a credibilidade. Dosimetria da pena mantida. Regime inicial fechado adequadamente imposto. Análise da detração que compete ao Juízo das Execuções Criminais. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação nº 3005429- 53.2013.8.26.0320, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Camargo Aranha Filho, j .05/05/2016) – Grifo nosso Não se pode olvidar que o réu foi preso em flagrante delito, surpreendido pelos guardas municipais na posse de um botijão de gás envolto em uma blusa de moletom, o que revela nítido propósito de ocultá-lo. Não obstante, ele admitiu aos guardas municipais a prática do crime em concurso de agentes com pessoa não identificada, que afirma atender pela alcunha de “Lagoa” e ainda forneceu as características físicas. Outrossim, restou devidamente comprovada a qualificadora do rompimento de obstáculo, tendo em vista o laudo pericial a fls. 167/183. Neste passo, mister a condenação do réu pelo delito imputado na denúncia. DA DOSIMETRIA DA PENA Seguindo o critério trifásico, na primeira fase deve ser aplicada pena-base acima

do mínimo legal, diante dos maus antecedentes (Fls. 63/71), bem como pela existência de duas qualificadoras.

Não há dúvidas de que o furto cometido com mais de uma qualificadora deve ser apenado de forma mais rigorosa que aquele cometido com apenas uma, justamente porque se trata de fato mais grave. Se assim não fosse, o agente mais perverso com sua conduta duplamente qualificada seria premiado com pena semelhante aquele que realiza com uma qualificadora do furto. Haveria nítida afronta ao princípio da individualização da pena, postulado de fundo constitucional (art. 5º, XLVI, da CF/88).

É com base nesse primado que se admite, nas hipóteses de pluralidade de qualificadoras do mesmo tipo penal, a utilização de uma delas para qualificar o crime e as demais ou i) para a exasperação da pena-base ou para ii) agravá-la na segunda fase da dosimetria, caso incluída no rol do art. 61, II, do CP.

Não há como desconsiderar que a incidência de várias qualificadoras torna a conduta mais reprovável, atraindo uma resposta penal mais enérgica. Nessa senda, inadmissível seria o mesmo tratamento ao agente que pratica furto unqualificado e aquele que pratica o mesmo delito biqualeficado.

No ponto:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME). PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS DO DELITO. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. 1. Embora estabelecida a pena definitiva menor que 8 anos (5 anos e 4 meses de reclusão), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime: o fato se deu mediante concurso de agentes), o que justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no furto, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo, como feito no presente caso. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1630537/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se que o réu é multi-reincidente específico (Fls. 63/71: Processos nº 0008573-76.2016.8.26.0451, 0014644-94.2016.8.26.0451), razão pela qual as penas deverão ser exasperadas.

Ausentes circunstâncias atenuantes.

A confissão na fase policial não pode ser invocada como circunstância que atenua a pena.

Ademais, a confissão em solo policial não foi integral, pois o réu negou a prática do crime, imputando a subtração a um comparsa e que ele "apenas ajudou a carregar os objetos".

Se não bastasse, a confissão informal do réu em nada auxiliou no deslinde da ação penal, pois foi preso em flagrante delito na posse de um dos objetos subtraídos.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado, diante da reincidência específica ostentada pelo réu e maus antecedentes.

Incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois ausentes os requisitos.

Ante o exposto, requeiro seja julgada procedente a presente ação, condenando-se o réu nos

Dada a palavra ao(à)(s) nobre(s) defensor(a)(es) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juiz(a), Durval Alexandre Antônio De Almeida foi denunciado como incurso no artigo 155, p. 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Segundo a denúncia (fls.124-125) no dia 7 de setembro de 2022, por volta de 09h10min, na Rua da Palma, n. 2790, Paulista, nesta cidade e comarca de Piracicaba-SP, DURVAL ALEXANDREANTONIO DE ALMEIDA, qualificado e indiciado a fls. 07-08,

agindo em concurso e com identidade de desígnios com pessoa não identificada nos autos, subtraiu, para si ou para outrem, um botijão de gás modelo doméstico, cor verde, um aparelho de som, uma lavadora de roupa, um notebook, um instrumento musical denominado loop station, um retroprojektor e um megafone pertencentes a Diego Augusto do Vale Moraes. Segundo foi apurado, o denunciado e seu comparsa não identificado arrombaram a janela (laudo a ser oportunamente juntado aos autos), ingressaram na casa da vítima e se apoderaram dos objetos acima descritos. Na sequência, quando carregava na via pública o botijão de gás, o denunciado foi abordado e confessou a subtração na companhia de pessoa conhecida por "Lagoa", mas não apontou onde estavam os demais objetos furtados. Na Delegacia de Polícia, afirmou que apenas auxiliou "Lagoa" a carregar os objetos (fls. 07-08). Auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 14.

Na delegacia, o guarda civil Francisco Dernival Miranda Junior disse que: "Que, na data e horário dos acontecimentos, estava com seu parceiro de farda, ora testemunha, em patrulhamento de rotina pela rua da Palma, nesta urbe, quando se depararam com o indiciado, que trazia em suas costas um botijão de gás envolto por uma blusa de moletom, o que despertou suspeitas. Que, realizada a abordagem, com o suspeito, nada de ilícito foi localizado. Que, indagado, confessou que, na companhia de um de tal de "Lagoa", havia subtraído o botijão e diversos outros itens do interior da residência situada na Rua Madre Cecília, 1453, tudo após prévio arrombamento. Que o averiguado não esclareceu quem era o tal "Lagoa" nem onde estavam as demais coisas furtadas. Que, de imediato, fizeram contato com a vítima, a qual confirmou o furto dos seus pertences, reconhecendo como seu, sem qualquer dúvida, o botijão localizado em poder do implicado. Que restou apurado, ainda, que o indiciado ingressou na residência após arrombar uma das janelas do imóvel." (fls.4)

O guarda civil Juvenal Estevão de Macedo disse que: "Que, na data e horário dos acontecimentos, estava com seu parceiro de farda, ora condutor, quando, ao realizar patrulhamento pela rua da Palma, nesta urbe, se depararam com o indiciado, a quem decidiram abordar. Que a fundada suspeita decorreu do fato dele estar trazendo consigo um botijão de gás envolto por uma blusa de moletom. Que, realizada a abordagem, com o suspeito, nada de ilícito foi localizado. Que, indagado, confessou que, na companhia de um de tal de "Lagoa", havia subtraído o botijão e diversos outros itens do interior da residência situada na Rua Madre Cecília, 1453, tudo após prévio arrombamento. Que o averiguado não esclareceu quem era o tal "Lagoa" nem onde estavam as demais coisas furtadas. Que, de imediato, fizeram contato com a vítima, a qual confirmou o furto dos seus pertences, reconhecendo como seu, sem qualquer dúvida, o botijão localizado em poder do implicado. Que restou apurado, ainda, que o indiciado ingressou na residência após arrombar uma das janelas do imóvel." (fls.5)

Ouvida a vítima Diego Augusto Do Vale Moraes disse que: "Reside no imóvel. Que, nesta data, estava na casa de sua genitora quando foi informado por guardas municipais de que alguns objetos haviam sido furtados do interior da sua residência. Que, de imediato, se deslocou até o imóvel, onde constatou que o portão e uma janela haviam sido arrombados, e diversos objetos, subtraídos de seu interior, dentre os quais um aparelho de som, uma máquina de lavar, um botijão de gás, um projetor de imagens, um notebook, um pedal de voz, além de outros itens. Que, ainda no local, reconheceu como seu, sem qualquer dúvida, o botijão de gás localizado com o implicado. Que acredita que o furto ocorreu nesta madrugada, oportunidade em que não se encontrava no imóvel." (fls.6)

Interrogado o acusado Durval disse que: "Que apenas acompanhou o autor do furto, a quem conhece pela alcunha de "Lagoa", auxiliando-o a carregar os itens subtraídos. Que desconhece o nome de "Lagoa", mas sabe que se trata de um homem moreno, com cerca de 25anos, que ostenta barbas e que vive na rua, nas cercanias da "Paulista". Que também desconhece o destino das demais coisas furtadas." (fls.7)

Laudo pericial juntado às fls.167-183

Às fls.63-71, juntada certidão de objeto e pé que indica ser o réu reincidente.
(Processo nº0008573-76.2016.8.26.0451 - art. 155 -Trânsito em julgado em 09/06/2017 - 0014645-31.2006.8.26.0451 - art. 155 - 09/02/2007 Trânsito em Julgado do Réu)

(Reincidência: Processo nº 0014644-94.2016.8.26.0451- art. 155 - Pena cumprida em 24/06/2022)

- DA INSTRUÇÃO EM AUDIÊNCIA:

Durante a instrução, foram colhidos os seguintes elementos probatórios:

Ouvido o guarda municipal Francisco Dernival Miranda Junior disse que, na data dos fatos, visualizou o acusado carregando um botijão de gás envolto em uma blusa de moletom. O indivíduo se portou de forma nervosa e foi abordado, sendo que o acusado confessou os fatos, afirmando que o furto de alguns objetos ocorreu mediante arrombamento. No local dos fatos, foi verificado que a residência possuía sinais de arrombamento e a vítima foi localizada, reconhecendo o objeto como de sua propriedade.

Ouvido o guarda municipal Juvenal Estevão de Macedo disse que, no dia dos fatos, realizando patrulhamento de rotina, visualizou o acusado carregando um botijão de gás envolto em uma blusa de moletom. O indivíduo se portou de forma nervosa e foi abordado, sendo que o acusado confessou os fatos e teria ido duas vezes no local dos fatos, uma vez com o coautor "Lagoa" e posteriormente sozinho.

A vítima Diego Augusto Do Vale Moraes não foi localizada e o Ministério Público desistiu de sua oitiva.

Por fim, interrogado Durval disse que: "

- DA ILICITUDE DA APREENSÃO DO ACUSADO

É premente o reconhecimento da ilicitude da abordagem do acusado que ensejou a prisão.

É possível constatar que a prisão do acusado se deu após verdadeira busca e apreensão efetuada por guardas municipais após visualizarem o acusado e realizado sua abordagem. Como facilmente se percebe, os guardas civis municipais deliberaram por fazer observações e efetuarem abordagens.

Ou seja, o acusado não foi surpreendido em situação imediata de flagrante que permitiria a intervenção dos guardas municipais. O encontro objeto furtado em seu poder foi precedido de diligência típica de atividade policial, já que efetuaram verdadeira busca e apreensão junto ao suspeito - atividade está para a qual não possuem competência. Tampouco há de se reconhecer que os guardas perseguiram o acusado ou mesmo tivessem qualquer notícia dos fatos anteriormente.

A Constituição Federal é clara nesse sentido. Compete às policiais civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, o exercício da atividade de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, assim como compete às polícias militares a atividade de polícia ostensiva e a preservação da ordem pública (Constituição Federal, artigo 144, parágrafos 4º e 5º). Já às guardas municipais, constituídas pelos Municípios, estão nada mais que simplesmente destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações (Constituição Federal, artigo 144, parágrafo 8º).

A respeito do tema, o ilustre constitucionalista José Afonso da Silva assim se posiciona: "Os constituintes recusaram várias propostas no sentido de instituir alguma forma de Polícia Municipal. Com isso, os Municípios não ficaram com qualquer responsabilidade específica pela segurança pública. Ficaram com a responsabilidade por ela na medida em que, sendo entidades estatais, não podem eximir-se de ajudar os Estados no cumprimento dessa função. Contudo, não se lhes autorizou a instituição de órgão policial de segurança, e menos ainda de polícia judiciária. A Constituição apenas lhes reconheceu a faculdade de constituir Guardas Municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Aí, certamente, está uma área que é de segurança: assegurar a incolumidade do patrimônio municipal, que envolve bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens patrimoniais, mas não é de polícia ostensiva, que é função da Polícia Militar. Por certo que não lhe cabe qualquer atividade de polícia judiciária e de apuração de infrações penais que a Constituição atribui com exclusividade à Polícia Civil (art. 144, § 4º), sem a possibilidade de delegação às Guardas Municipais."

(Comentário Contextual à Constituição. 3ª ed., São Paulo. Malheiros, 2007, pp. 638/639).

Ou seja, o limite constitucional está claramente delineado. E ainda que a Lei nº

13.022/14 tenha instituído normas gerais para as guardas municipais, é preciso reconhecer que devem ser interpretadas conforme o que estabelece a Constituição Federal, de modo que o que extrapolar a Carta Magna não pode ser julgado válido. Reconhecer a licitude da ação dos guardas municipais no presente caso seria o mesmo que permitir que qualquer um do povo, sem qualquer atribuição ou competência para tanto, passasse a investigar terceiros apenas suspeitos da prática de ilícito penal, procedendo-se verdadeiras buscas e investigações, como se policiais fossem. Aliás, como bem consignou o Eminentíssimo Desembargador Péricles Piza no voto vencedor no julgamento da apelação nº 0004993-09.2017.8.26.0320, da 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, julgado em 28 de janeiro de 2019, “qualquer do povo pode, de fato, dar voz de prisão a pessoas que estejam a cometer crimes em sua frente. É vedado, no entanto, que os cidadãos investiguem os indivíduos com quem partilham da vida em sociedade, bem como lhes é proibido realizar diligências com o fim de verificar o cometimento de ilícitos criminais. Justamente com o objetivo de retirar dos indivíduos o poder de investigar e punir delitos, impedindo assim que o Direito Penal sucumbisse à mera vingança privada, delegou-se o poder de punir ao Estado”.

Assim, a conduta dos guardas municipais não pode ser justificada à luz do artigo 301 do Código de Processo Penal, porque a autorização ali prevista é apenas para os casos de imediato flagrante, como, por exemplo, na situação em que a pessoa é surpreendida subtraindo bem de terceiro, o que exige e permite a rápida intervenção. Se a prisão depender de ato investigativo, como a busca pessoal, o ato não pode ser legitimado, caso não praticado por quem legalmente investido para tanto.

E no presente caso, ficou evidente que a situação de possível flagrante só se deu após a prática de ato investigativo pelos servidores municipais que deliberaram por fazer observação da conduta de adolescentes e transeuntes. A propósito, em diversos casos semelhantes, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu a ilicitude da conduta dos guardas civis municipais (Embargos Infringentes e de Nulidade n.º 0021357-54.2015.8.26.0602, E. TJSP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Mário Devienne Ferraz; Apelação n.º 0002952-46.2011.8.26.0137, E. TJSP, 2ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Almeida Sampaio, j. 20/05/13; Apelação nº 3005009-21.2013.8.26.0038, 2ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Almeida Sampaio, j. em 07.03.2016.

Portanto, no caso, ao suspeitar do comportamento do acusado e suspeitarem da prática de crime, competia aos guardas acionar os órgãos policiais competentes. Não havia motivo para que, em vez disso, tornassem a iniciativa da investigação, efetuado abordagem e apreensão do bem.

Logo, a postura em comento violou as normas supracitadas (artigo 144 da CF e artigos 301 e 302 do CPP). Com isso, os elementos dela obtidos e os que dela derivaram – prova da autoria e da materialidade – estão igualmente contaminados e devem ser desentranhados dos autos, diante do que determina a norma em apreço, bem como seu § 1º: “São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras”.

Realizado o desentranhamento, conclui-se que inexistente a prova da autoria e da materialidade, devendo, então, ser o acusado absolvido por insuficiência de provas.

- DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

Como as provas produzidas no presente feito não foram aptas a demonstrar, de forma cabal, a caracterização do crime imputado, tem-se que a prolação de um decreto absolutório é a única medida adequada ao caso, para que se respeite o princípio basilar do in dubio pro reo, tudo nos termos do artigo 386, inciso VII, Código de Processo Penal.

Os guardas civis não apresentaram versão coerente acerca do que o acusado teria confessado.

- DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL

Não juntados aos autos os vídeos ou o depoimento de testemunha que tenha presenciado a subtração do bem, não é possível garantir que o réu foi o responsável pelo delito previsto no artigo 155, CP.

Nenhuma das testemunhas indicou em seus depoimentos que visualizou que o indivíduo preso era a pessoa que praticou o furto. A suposta confissão informal ao guarda, é insuficiente como prova de autoria do furto, uma vez que não colhida com garantia de contraditório e ampla defesa e, nem mesmo, no inquérito policial. Assim, somente existe nos autos a comprovação de que o requerido estava em posse do bem subtraído quando detido.

De rigor, portanto, a desclassificação da sua conduta para a prevista no artigo 180 do Código Penal.

- DA FIXAÇÃO DA PENA

Subsidiariamente, na remota possibilidade de condenação, passa-se a discorrer sobre a pena.

a) Afastamento da qualificadora do art. 155, §4º, I, CP

De início, impõe-se o afastamento da figura qualificada do art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

Ora, a prática do furto qualificado mediante o rompimento ou destruição de obstáculo pressupõe a superação/destruição de algo utilizado para a proteção da coisa. Nesse sentido, leciona Rogério Greco, ao apontar que, “[...] em sede doutrinária, considera-se obstáculo tudo aquilo que tenha a finalidade precípua de proteger a coisa e que também não seja a ela inerente” (GRECO, Rogério. Código Penal: comentado. 5. ed. Niterói: Impetus, 2011, p. 417).

Trata-se, pois, de figura qualificada que deixa vestígios. É imprescindível, por isso, a realização de um laudo que aponte o rompimento ou a destruição, eis que se trata de infração que deixa vestígios (CPP, art. 158).

Não é diferente o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao apontar que “A incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto” (AgRg no AREsp 1002431/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

O laudo pericial juntado aos autos, todavia, não aponta que houve rompimento ou da destruição do obstáculo.

No mais, a própria vítima indicou que o seu carro estava destravado.

Perceba-se, portanto, que não ficou demonstrada a configuração da qualificadora prevista pelo art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

b) Afastamento da qualificadora referente ao concurso de pessoas

Inegável que não ficou comprovado que concorreu “lagoa” para a prática do crime de furto, tendo em vista que os guardas civis ouvidos não presenciaram o acontecido e a vítima não foi localizada.

Sabe-se que, as pessoas devem estar conectadas psicologicamente, havendo adesão subjetiva à conduta criminosa de outrem, visando a um fim comum. Cezar Roberto Bitencourt brilhantemente elucida que: “A causalidade física é apenas um fragmento do complexo problema do concurso de pessoas, que exige também um liame subjetivo para completar-se. (...) Assim, inexistindo-se o nexu causal ou o liame subjetivo, qualquer dos dois, não se poderá falar em concurso de pessoas” (In Tratado de Direito Penal – Parte Especial 3, 17. ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012).

Assim, não é possível encontrar supedâneo em nada nos autos para sustentar a versão acusatória, sendo de rigor que se afaste a qualificadora do concurso de agentes prevista pelo inciso IV, § 4º, do art. 155 do CP

c) Da pena-base

Afastada a qualificadora, aplica-se ao caso o caput do artigo 155, CP. De rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal, sendo certo que, a despeito dos maus antecedentes, trata-se de circunstância que deve ser apreciada em segunda etapa de dosimetria. A consideração de outras condenações como maus antecedentes redundará em bis in idem.

Sem prejuízo, a confissão do acusado deve ser integralmente compensada com a reincidência, de forma que a pena deve ser mantida no mínimo legal.

- REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, conforme disposto nas Súmulas 718 e 719 do Supremo

Tribunal Federal, assim como a Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça e, ainda, no art. 33, § 3º, do Código Penal, não se pode apelar à gravidade em abstrato do delito para justificar a imposição de regime mais gravoso para o caso. É certo, ademais, que, conforme se infere da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso por analogia, a reincidência, por si só, não pode justificar a escolha do regime mais gravoso para o caso. Pugna-se, assim, pela fixação do regime inicial aberto.

Segundo decidiu o STF no julgamento do HC 135.164/MT (j. 23/04/2019), tais casos de furto de bens de pequeno valor devem ser tratados de maneira ainda mais branda, aplicando-se diretamente o regime inicial aberto.

- DO RECURSO EM LIBERDADE

Por fim, considerando que o acusado praticou crime com violência ou grave ameaça e não representa perigo à segurança da sociedade, requer-se que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

DURVAL ALEXANDRE ANTONIO DE ALMEIDA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque no dia 7 de setembro de 2022, por volta de 09h10, na Rua da Palma, nº 2790, Paulista, nesta cidade e comarca de Piracicaba-SP, agindo em concurso e com identidade de desígnios com pessoa não identificada nos autos, subtraiu, para si ou para outrem, um botijão de gás modelo doméstico, cor verde, um aparelho de som, uma lavadora de roupa, um notebook, um instrumento musical denominado loop station, um retroprojeto e um megafone pertencentes a D.A.V.M.

Segundo a denúncia, o réu e seu comparsa não identificado arrombaram a janela, ingressaram na casa da vítima e se apoderaram dos objetos acima descritos.

Na sequência, quando carregava na via pública o botijão de gás, o réu foi abordado e confessou a subtração na companhia de pessoa conhecida por "Lagoa", mas não apontou onde estavam os demais objetos furtados.

Na Delegacia de Polícia, afirmou que apenas auxiliou "Lagoa" a carregar os objetos (fls. 07/08).

A denúncia foi recebida (fls. 130/131), o réu citado (fls.139), apresentando resposta escrita, na qual requereu a revogação da prisão preventiva (fls. 143/147). O recebimento da denúncia foi mantido, mantendo-se a prisão preventiva do réu e designando-se audiência (fls. 154/156).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 testemunhas comuns, sendo o réu interrogado. Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

I - Da preliminar

Pleiteia a Defesa, o reconhecimento da nulidade do processo, em razão da prisão realizada por guardas municipais. Argumenta que houve diligência típica de atividade policial, não permitida aos guardas municipais.

Não há, contudo, qualquer nulidade na prisão em flagrante do réu.

Não se verifica qualquer abuso ou ilegalidade na diligência efetuada pelos guardas municipais que apenas abordaram o réu, ao vê-lo carregando um botijão de gás coberto por um moletom, pela rua.

Por fim, a Lei nº 13.022/14 conferiu expressamente à Guarda Municipal a atribuição de polícia ostensiva, nos termos do artigo 3º da referida legislação, que assim dispõe: "Artigo 3º. São princípios mínimos de atuação das guardas municipais: I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas; II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; III - patrulhamento preventivo; IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e V - uso progressivo da força".

De qualquer modo, nada obstante o disposto no artigo 144, parágrafo 8º, da Constituição Federal, é certo que, à luz do artigo 301 do Código de Processo Penal, não há uma proibição de que os guardas municipais prendam alguém em flagrante, haja vista que qualquer pessoa do povo também pode fazê-lo.

E, no caso concreto, ao contrário do postulado pela Defesa, o réu foi abordado na posse do botijão subtraído, havendo flagrante, consoante prevê o artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PELA PRISÃO EM FLAGRANTE POR GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS.

INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 301 DO CPP. DOSIMETRIA. AUMENTO DA BASILAR.

DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS, ALÉM DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E

CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE

FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta

Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso,

firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao

recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração,

ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja

possível a concessão da ordem de ofício. II - No presente caso, com relação à

alegada nulidade da prisão em flagrante realizada por guardas municipais, cumpre

registrar que é assente nesta Corte Superior a orientação de que os integrantes da

guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo. Contudo,

também é firme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça no

sentido de que, "nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer

pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há

qualquer óbice à sua realização por guardas municipais. Precedentes" (HC n.

357.725/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 12/05/2017). Precedentes.

III - Destarte, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado v. aresto

reprochado, bem como no auto de prisão em flagrante lavrado pela autoridade

policial, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art.

301 do Código de Processo Penal. Ademais, no que tange ao pleito defensivo de

reconhecimento da ilicitude das provas, verifica-se que o v. aresto vergastado

afastou motivadamente a alegada nulidade da busca e apreensão pessoal, sob o

fundamento de que havia fundadas suspeita para a referida diligência porquanto, em

patrulhamento de rotina em local conhecido pelo tráfico de drogas (cracolândia), os

guardas civis visualizaram o acusado em atitude suspeita, uma vez que tentou

empreender fuga ao se deparar com a viatura, levando à abordagem que resultou na

apreensão de entorpecentes de natureza extremamente deletéria. Precedentes. IV - De

mais a mais, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo

fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as

conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas,

providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas

corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo

processual. Precedentes. V - Quanto à pretensão de revisão da dosimetria da pena,

referente à redução da basilar ao mínimo legal ou a patamar próximo, tem-se que

melhor sorte não assiste ao paciente porquanto, em que pese a quantidade de drogas

não ser tão relevante, tratando-se de "33 (trinta e três) porções de maconha, com

peso líquido de 74,7g; 21 (vinte e uma) porções de cocaína, com peso líquido de

14,6g; 1 (uma) pedra de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 58,6g" (fl.

11), a sua diversidade e natureza extremamente destrutiva, em especial com relação

ao crack, legitimam o aumento da pena-base em 1/5 (um quinto), como realizado no

édito condenatório e mantido pelo acórdão recorrido, ainda mais diante da

existência de diversas anotações criminais, tendo o paciente sido preso em

flagrante enquanto estava em liberdade provisória, o que evidencia maior

reprovabilidade da conduta. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (HC n.

742.941/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft),

Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

E mais:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA

LEI N. 11.343/2006. ILICITUDE DAS PROVAS. ATUAÇÃO INVESTIGATIVA DA GUARDA

MUNICIPAL. ANULAÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME

PARA USO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA

MINORANTE NA FRAÇÃO MÁXIMA. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexiste ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais. Conforme compreensão da Sexta Turma desta Corte Superior, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa" (AgRg no HC 667.413/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 16/6/2021). 2. Na espécie, os guardas municipais, em patrulhamento de rotina, avistaram o exato momento em que o agravante realizava a venda de entorpecentes, razão pela qual o prenderam em flagrante. 3. O pleito de desclassificação da conduta de tráfico para a de uso de entorpecente demandaria inevitável revolvimento de matéria fático-probatória, o que se não mostra viável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. De acordo com o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 5. A Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 6. No caso em tela, não foi reconhecida a incidência da minorante com base na dedicação do paciente à atividade criminosa, tendo em vista a anterior prática de atos infracionais, com observância aos pormenores da situação concreta e respeitando os critérios estabelecidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sendo excluída a possibilidade de aplicação do pretendido redutor. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 703.036/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)

II - Do mérito

No mérito, a ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 14.

2) Da autoria

A autoria criminosa é certa e deve ser atribuída ao réu.

Na fase inquisitiva, o réu negou a autoria delitiva. disse que apenas acompanhou o autor do furto, a quem conhece pela alcunha de "Lagoa", auxiliando-o a carregar os itens subtraídos. Desconhece o nome de "Lagoa", mas sabe que se trata de um homem moreno, com cerca de 25 anos, que ostenta barbas e que vive na rua, nas cercanias da "Paulista". Também desconhece o destino das demais coisas furtadas (fls.07/08). Em Juízo, o réu afirmou que estava no bairro Monte Cristo. É dependente de drogas e queria fazer uso. Um rapaz de apelido "Lagoa" disse que tinha subtraído vários objetos de uma casa e precisava buscar os bens. Ele disse que daria um dinheiro para quem o ajudasse. "Lagoa" mostrou onde era a casa, mandou que ficasse na esquina e "Lagoa" entrou na casa, pegou o botijão e lhe entregou. Estava saindo, quando foi abordado por um policial a paisana. Ele perguntou o que estava levando e lhe disse que sabia que tinha errado. Colocou o botijão de gás no chão e ele perguntou onde tinha pegado o botijão. Falou que iria vender o botijão e, por isso, ele chamou a Guarda Civil. Ficou esperando a chegada dos guardas civis. Foi colocado na viatura e levou os guardas civis na residência da vítima. Falou aos guardas que não entrou na residência. Foi apresentado no Plantão Policial. Não ajudou "Lagoa" a pegar os bens. Foi só buscar o botijão de gás e não os demais bens. Havia outros bens, mas não os carregou. "Lagou" abriu o portão da casa e entrou, depois saiu com o botijão e lhe entregou.

A autoria foi amparada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos, sob o crivo do contraditório. Vejamos.

Ouvida apenas na fase inquisitiva, a vítima D.A.V.M. declarou que reside no imóvel. Na data dos fatos, estava na casa de sua genitora, quando foi informada por guardas municipais de que alguns objetos haviam sido furtados do interior da sua residência. De imediato, se deslocou até o imóvel, onde constatou que o portão e

uma janela haviam sido arrombados e diversos objetos subtraídos de seu interior, dentre os quais um aparelho de som, uma máquina de lavar, um botijão de gás, um projetor de imagens, um notebook, um pedal de voz, além de outros itens. Ainda no local, reconheceu como seu, sem qualquer dúvida, o botijão de gás localizado com o réu. Acredita que o furto ocorreu na madrugada, oportunidade em que não se encontrava no imóvel (fls. 06).

O guarda municipal Francisco Dernival Miranda Júnior informou que passavam pela rua, quando viram o réu carregando o botijão, envolto em uma blusa de moletom. Quando viu a viatura, o réu ficou muito nervoso, a todo momento olhando e lado. Ele foi abordado e confessou que tinha acabado de efetuar o furto com "Lagoa", pessoa que não foi identificada. Ele os levou à residência, disse que tinham arrombado a casa. No local, viram que a casa aparentava arrombamento. Fizeram contato com a vítima que foi ao local e reconheceu o botijão como sendo seu. Outros bens foram furtados, mas não foram localizados, porque o réu não disse onde os tinha deixado. Para os guardas civis, o réu falou que ele e o comparsa arrombaram a casa e subtraíram os bens. Não conhecia o réu.

No mesmo sentido, o depoimento do também guarda municipal Juvenal Estevão de Macedo, segundo o qual faziam o patrulhamento de rotina, quando se depararam com o réu levando um botijão de gás coberto com um moletom. Ao se aproximar, o réu demonstrou nervosismo. Ele foi abordado e acabou confessando que tinha subtraído alguns objetos de uma residência, juntamente com "Lagoa". Depois, ele retornou à casa, para subtrair, sozinho, o botijão de gás. O réu disse que ele e o comparsa tinham subtraído muitos bens. Ele os levou até a residência, que estava arrombada. Os outros objetos não foram localizados. Não identificaram "Lagoa". A janela estava arrombada e a porta tinha marcas de tentativa de arrombamento. A vítima confirmou que o botijão era dela e deu falta dos outros objetos subtraídos.

Com efeito, a prova é suficiente para a certeza da acusação.

O réu negou a prática da subtração, alegando que só auxiliava indivíduo conhecido como "Lagoa" a carregar os itens subtraídos. Não soube dizer o destino dos demais bens subtraídos. Judicialmente, o réu explicou que foi ajudar "Lagoa" para levar os bens subtraídos. Negou que tivesse entrado na casa ou arrombado qualquer porta ou janela.

A vítima não presenciou a subtração, porque não estava em sua residência. Soube dos fatos por contato feito pelos guardas civis. Esteve em sua residência e verificou que o portão e a janela tinham sido arrombados e vários bens subtraídos.

Os guardas municipais descreveram que avistaram o réu na via pública, carregando um botijão de gás coberto por um moletom, nas costas. Realizada a abordagem, o réu confessou que, na companhia de um terceiro de alcunha "Lagoa", havia subtraído o botijão de gás e outros itens da residência da vítima, após arrombamento de uma das janelas. O réu não soube indicar o local onde estavam os demais bens subtraídos, nem esclarecer quem era "Lagoa".

Embora o réu tenha negado a participação no delito, dizendo que apenas auxiliou "Lagoa" na empreitada criminoso, o certo é que foi flagrado pelos guardas municipais sozinho e carregando o botijão de gás.

E mais, se estivesse apenas auxiliado o comparsa, essa ação já traz a coautoria. Note-se que ele iria dividir o proveito do crime com "Lagoa" e, sem ele para carregar o botijão, o crime poderia não ter ocorrido.

Por fim, o fato de o réu ter sido abordado na posse de parte da res, já faz presumir-se a autoria, cabendo ao próprio acusado a tarefa de afastar tal presunção.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto simples - Recurso defensivo - Absolvição - Fragilidade - Materialidade e autoria demonstradas - Apreensão da res em poder do acusado gera a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova - Pena reclusiva mantida - Dia-multa fixado no valor unitário mínimo legal - Regime inalterado dada a comprovada presença de antecedentes criminais - Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos - Ausência de recurso ministerial nesse sentido - Recurso parcialmente provido". (TJSP - Apelação Criminal 0000318-78.2015.8.26.0544. Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal. Relator

(a): Fernando Torres Garcia - j. 20/08/2020 - grifei)

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado pelo concurso de agentes - Sentença condenatória - Pleito absolutório inadmissível - Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva - Réu que foi surpreendido na posse do produto furtado, sem explicação plausível - Prova oral suficiente para a condenação - (...)". (TJSP - Apelação Criminal 1500587-42.2018.8.26.0575. Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto - j. 02/03/2021 - grifei)

"APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO - ARTIGO 155, § 1º e § 4º, inciso I, DO CÓDIGO PENAL - Subtração de diversos itens de vestuário do interior de estabelecimento comercial, mediante quebra da vidraça da loja, durante repouso noturno - Recurso defensivo que não questiona a autoria delitiva. Confissão. Apreensão em flagrância em posse da res. Ainda, palavras da vítima e dos servidores policiais seguras e consistentes. Condenação mantida - (...). RECURSO NÃO PROVIDO". (TJSP - Apelação Criminal 1501430-28.2019.8.26.0201. Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): José Vitor Teixeira de Freitas - j. 28/02/2021 - grifei)

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SIMULAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA E VIOLÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. REFORMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. "RES" NA POSSE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS SUFICIENTES A CONVENCER DO DECRETO CONDENATÓRIO. CONSUMAÇÃO. A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA COISA SUBTRAÍDA É O BASTANTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 59, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COMPROVADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO RÉU. (...) 4. Encontro de parte